

1501308-57.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... por crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. Já cumpriu todas as penas cominadas.

Na espécie, as versões apresentadas pelos acusados, pouco críveis e fantasiosas, restaram isoladas nos autos quando confrontadas com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito. Aliás, a ré Fabiana admite o crime de tráfico de drogas ao afirmar textualmente que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501308-57.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501308-57.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2264107/2021 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 20513062 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO,

1762/21/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2264107 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 1762/21/515

- DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FABIANA ELIZABETH MACANONI e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.FABIANA ELIZABETH MACANONI e HENRIQUE OSWALDO CARNEIRO NETO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso como incurso no art. 33, "caput" e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, em concurso material (art. 69), e FABIANA ELIZABETH MACANONI como incurso no crime do art. 333, "caput", ambos do Código Penal, por que, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 19h, na Avenida

Rio de Janeiro, bairro Rio Comprido, e Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 379, bloco V, apto. 32, Residencial Parque das Flores, nesta cidade e comarca, os acusados, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, previamente associados para o tráfico, traziam com eles, guardavam e mantinham em depósito, para fins de entrega a terceiros, as seguintes drogas: 282 pedras de cocaína na forma conhecida como crack, com peso líquido de 770,51g, 455 porções de Cannabis Sativa L., com peso líquido de 7,1kg, e 611 porções de cocaína, com peso líquido de 2,3kg.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, FABIANA ELIZABETH MACANONI, agindo em ocasião de calamidade pública, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para omitirem ato de ofício.

Após a apresentação das defesas preliminares (fls. 243/244), a denúncia foi recebida no dia pela decisão do dia 19 de novembro de 2021 (fls. 250/254).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final os réus foram interrogados.

Em debates, a Dra. Promotora de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a parcial procedência da ação penal.

A Douta Defesa do réu Henrique pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, questionando as provas produzidas, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente requereu a fixação da pena no mínimo legal, e o regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, facultando-se o apelo em liberdade.

Por fim, a Douta Defesa da ré Fabiana postulou a absolvição quanto aos crimes do artigo 35, da Lei de Drogas e 333, do Código Penal, por insuficiência de provas. No tocante ao delito do artigo 33, da Lei de Drogas, postulou a fixação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser aplicado o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituindo a pena corporal por restritiva de direitos, facultando à ré a possibilidade de interposição de recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa está demonstrada pelos Autos de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16 e 23/25), Fotografias (fls. 99/115), Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (fls. 122/127), Laudo de Exame Químico - Toxicológico (fls. 190/193), Laudo Pericial dos Eppendorfs (fls. 293/296), bem como pelas demais provas carreadas aos autos.

A autoria é certa quanto ao crime de tráfico de drogas para ambos os réus e para o crime do artigo 333, do Código Penal, para a ré Fabiana.

A ré FABIANA ELIZABETH MACANONI, permaneceu em silêncio durante a fase extrajudicial. Em juízo, ao ser interrogada, a ré negou os crimes, aduzindo que na data dos fatos foi buscar a testemunha Kevin no mercadinho Silva para ajudá-la com a mudança. De repente os policiais a abordaram. O corréu, que não conhecia, já estava detido na parte de trás da viatura. Os policiais os ameaçaram se não assumissem o tráfico de drogas eles forjariam um flagrante por este crime com apreensão de mais de 400 porções de drogas. Pertencia a um grupo de whataspp do bairro e não sabia que o réu também estava. Os policiais pegaram o telefone do acusado. Os policiais queriam que desbloqueasse o seu telefone celular. Foi

agredida pelos policiais que ainda a revistaram passando a mão nos seus seios. Foi enforcada pelos milicianos, que conseguiram desbloquear o seu telefone, oportunidade em que eles visualizaram algumas fotografias de drogas, que desconhece completamente. Os policiais pegaram drogas da viatura e atribuíram a Henrique, que jamais tinha visto em data anterior. Os policiais queriam R\$100.000,00, uma metralhadora e uma pistola .40 para ser liberada. Novamente aduziu ter sido agredida fisicamente pelos milicianos. Teve infecção de urina e recebeu golpes nas costas e enforcamento. Tudo isso em plena via pública. Guardou realmente substâncias entorpecentes em sua casa, pois estava endividada e ameaçada de morte. É usuária de droga. O rapaz que se identificava como "Zé Meningite", que lhe propôs para guardar a droga em sua casa por uma semana em troca do pagamento da sua dívida. Recebeu uma coronhada na cabeça pelos policiais e o seu braço foi deslocado. Perdeu parte do movimento de um dos dedos. O veículo em questão estava na posse da sua colega Marcia. As chaves estavam em seu poder. Marcia e Kevin não possuíam habilitação para condução de veículos e, por isso, estava dirigindo o automóvel. Dentro do automóvel não havia drogas. Atualmente tem 43 anos de idade. Nunca foi presa ou processada anteriormente. Reside em Jacareí com seus genitores e em um apartamento no bairro Nova Jacareí. Fazia três meses que tinha chegado de Ilhabela. Trabalha como comerciante (tem uma empresa de pallets). Tem dois filhos (25 e 23 anos). Nunca foi presa ou processada criminalmente.

O réu HENRIQUE OSWALDO CARNEIRO NETO, interrogado em solo policial, negou o crime, aduzindo que na data dos fatos estava em companhia de sua esposa Jaqueline no local indicado na denúncia quando foi abordado por policiais militares que realizaram busca pessoal e nada encontraram. Os milicianos passaram a vasculhar o aplicativo whatsapp do seu telefone celular e "viram umas paradas do grupo do bairro" em que os componentes avisavam sobre a presença dos policiais na região, bem como mencionavam uma pessoa que estava no mercadinho. Mesmo nada sendo encontrado consigo os policiais o colocaram na viatura policial e rumaram até um mercadinho da rua, onde abordaram uma mulher que nunca havia visto antes. Aduziu, ainda, que nenhum "tucho" de drogas foi encontrado em seu poder e não indicou ou fez qualquer referência a mulher abordada no mercadinho. Em juízo, ao ser interrogado, o réu voltou a negar o crime, aduzindo que não estava na posse de qualquer porção de droga. O flagrante foi forjado. Reside na viela Olinda juntamente com Jaqueline e as filhas dela, que é próxima da esquina onde foi abordado pelos policiais. Avistou os milicianos entrando no bairro. Teria todas as condições para correr, até porque já "tirou" 10 anos de cadeia e não queria ser preso de novo. Não conhece a corré Fabiana. Fazia 4 meses que estava na rua e se encontrava trabalhando regularmente na serralheria. Mudou de vida e demorou bastante para conseguir o emprego. O seu patrão iria registrá-lo. Na abordagem foi agredido pelos milicianos e recebeu um soco no estômago. A abordagem ocorreu por volta de 16h00. Não portava qualquer porção de droga. Em seguida a corré Fabiana foi abordada pelos mesmos policiais e espancada pela guarnição. Ficou até triste porque ela foi torturada e estrangulada pelos milicianos. O PM Gonçalves é conhecido na região onde mora como sendo policial que fica "forjando" flagrantes. Não possuía qualquer telefone celular e não sabe como realizaram qualquer ligação com a corré Fabiana. Já tinha sido abordado pelos mesmos policiais em data anterior. Disse ao Delegado que foi agredido pelos policiais, assim como Fabiana, mas não constou do seu depoimento. Estava com a barriga marcada em razão do soco recebido. Atualmente tem 28 anos de idade. Reside na cidade de Jacareí com a sua namorada. Tem uma filha e três enteadas. Trabalha como ajudante de serralheiro. Já foi preso e processado anteriormente por crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. Já cumpriu todas as penas cominadas.

Na espécie, as versões apresentadas pelos acusados, pouco críveis e fantasiosas, restaram isoladas nos autos quando confrontadas com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito. Aliás, a ré Fabiana admite o crime de tráfico de drogas ao afirmar textualmente que guardava drogas em sua residência a pedido de um indivíduo para pagamento de uma dívida. A confissão de Fabiana será devidamente

considerada oportunamente, mas ela está bem dissociada das demais provas amealhadas, que indicam que ela era a responsável direta pela distribuição de drogas naquela região e intimamente envolvida com o tráfico de drogas, não sendo utilizada como mera armazenadora de drogas para a quadrilha.

A testemunha KEVIN GOMES JULIANO declarou em fase policial que é amigo de Fabiana há três meses e na data do ocorrido ela o convidou a comparecer até o mercadinho Silva situado no bairro Rio Cumprido. No local indicado pela amiga, encontrou Fabiana, Marcia e mais um homem negro (que não sabe o nome). Neste momento, Fabiana acabou sendo abordada por policiais militares que passaram a questioná-la sobre o veículo GM Corsa verde placas DQF5718. Aduziu que o referido veículo é de responsabilidade de Marcia, funcionária da empresa Resende Construtora (proprietário do veículo). Mesmo assim os policiais exigiram a ida até o apartamento de Fabiana. Marcia seria a testemunha que acompanharia a diligência. Ocorre que Marica começou a passar mal e acabou sendo convidado pelos policiais a acompanhar a diligência na casa de Fabiana. No local Fabiana subiu com um dos policiais até o apartamento, tendo aguardado no veículo GM/Corsa em companhia do outro policial. Pouco tempo depois o policial que o acompanhava recebeu ligação do agente que subiu com Fabiana. Neste momento foi dispensado pelo policial, mas pediu para subir e ver como Fabiana estava e foi autorizado pelo policial. No imóvel de Fabiana, apesar de não acompanhar as buscas, viu uma mala grande com drogas no local. Em nenhum momento se apresentou como responsável pelo veículo GM/Corsa, afirmando que sequer sabe dirigir veículo automotor. Não presenciou as buscas policiais no automóvel e não sabe dizer se encontraram drogas. Não sabe dizer em poder de quem estavam as chaves do veículo GM/Corsa. Em juízo Ministério Público e Defesa desistiram da sua inquirição sob o crivo do contraditório.

A testemunha RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA, Policial Militar, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento regular quando na Rua Rio de Janeiro, bairro Rio Cumprido, nesta cidade, apurou juntamente com sua equipe que a pessoa de Henrique Oswaldo Carneiro Neto teria recebido "partida" de drogas da pessoa de Fabiana Elizabeth Macanoni, tanto que em abordagem do primeiro suspeito (em frente ao numeral 170) foram encontrados um telefone celular Motorola (model XT2053-5), 30 "buchas" de erva macera aparentando ser maconha, e 28 diminutas unidades de substância sólida aparentando ser crack. Durante os questionamentos Henrique admitiu ter recebido as substâncias de Fabiana, a qual foi abordada na mesma rua em frente ao "Mercadinho Silva" (nº 30), na posse de dois telefones celulares um Motorola (model XT2129-1) e Samsung, além da chave de um veículo. Fabiana foi questionada e admitiu ter entregado drogas a Henrique, indicando o veículo GM/Corsa, verde, placas DQF5718 onde haveria mais drogas. A chave de ignição era justamente aquela encontrada na posse dela. No veículo foi localizada uma sacola plástica contendo várias "partidas" totalizando 226 diminutas unidades de "crack" e 388 "buchas" de maconha. Com intuito de se ver livre, FABIANA disse que os policiais poderiam ficar com as drogas encontradas em seu veículo e outras que estavam em seu apartamento, oportunidade em que rumaram, simulando aceite, até o imóvel situado na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 379, bloco V, apto 32, Condomínio Residencial Parque das Flores, Jacareí/SP, onde a própria abordada indicou uma grande mala de viagem que continha em seu interior: a) 02 sacos com inúmeros flaconetes pretos vazios; b) 64 flaconetes (pretos e transparentes) contendo substância alvacenta aparentando ser cocaína; c) 28 porções (vários tamanhos) de substância que indicava ser crack; d) 01 balança de precisão; e) 01 pote plástico verde com várias lâminas de Gillete quebradas e um estilete; f) 06 porções de substância em pó esbranquiçada aparentando ser cocaína; g) 09 tabletes (tipo tijolo), 11 porções e 17 invólucros transparentes de erva prensada aparentando ser maconha; 541 pequenas unidades plásticas de substância em pó branca aparentando ser cocaína. Ainda, durante a diligência, a testemunha Kevin foi abordado no mercadinho porque se identificou como responsável pelo automóvel GM/Corsa. Fabiana trabalhava para um integrante de organização criminosa (PCC) denominado "PIMENTA", e Kevin alegou desconhecer a existência das drogas no veículo

e apartamento de Fabiana. Os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial. Em juízo, ouvido sob o crivo do contraditório, o policial apresentou basicamente a mesma versão. Naquela data não receberam qualquer denúncia anônima e apenas realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de venda de drogas. O acusado Henrique demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. E defronte ao ponto em que se encontrava é ponto de venda de drogas (biqueira usual de compra e venda de drogas). O réu estava entretido no telefone celular. Ao ser questionado sobre o relato apresentado durante o auto de prisão em flagrante o policial esclareceu que teria realizado uma entrevista com o indivíduo abordado e, por isso, consignou em seu depoimento que apurou que a droga apreendida em poder do réu Henrique teria sido entregue para ele pela ré Fabiana. Não conhecia o acusado Henrique de outras ocorrências. Não mexeu no aparelho celular encontrado em poder de Henrique.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha, Policial Militar ANSELMO DA SILVA GONÇALVES que participou da prisão em flagrante delito dos acusados. Durante a abordagem o acusado admitiu que restava realizando a venda de drogas, aduzindo que tinha saído da cadeia e precisava de dinheiro. Henrique declinou ter recebido as drogas da acusada Fabiana, que foi igualmente abordada. Durante entrevista Fabiana admitiu que havia drogas no interior do seu veículo, aduzindo ser a responsável pelo abastecimento de drogas na região. Ao receber voz de prisão em flagrante a ré ofereceu drogas aos policiais militares, afirmando que não poderia ser presa. Fabiana declarou que tinha grande quantidade de drogas em seu apartamento. Simularam aceitar a oferta e rumaram ao apartamento da acusada, onde realmente encontraram grande quantidade de substâncias entorpecentes. A ré assumiu a propriedade do veículo onde foram localizadas as drogas. Ela estava acompanhada da testemunha Kevin. Fabiana foi abordada na porta do mercado do lado de fora.

Pois bem.

As provas amealhadas aos autos são seguras para o desfecho condenatório para ambos os réus quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei de Drogas), exatamente como postulou o Ministério Público em sua manifestação final para.

Os relatos dos Policiais Militares são coerentes e harmônicos entre si quando descrevem a dinâmica da ocorrência, devendo ser observado, de início, que pequenas contradições são absolutamente normais e, no caso em tela, não comprometeram a prova produzida que muito bem caracteriza a empreitada criminosa desenvolvida pelos inculpados.

Segundo relatos dos milicianos o acusado Henrique foi avistado em atitude suspeita defronte a um local conhecido por ser ponto de venda de drogas. Ao ser abordado os milicianos encontraram em poder do réu diversas substâncias devidamente embaladas para venda (30 "buchas" de maconha e 28 porções de cocaína em forma de "crack"), além de um telefone celular. Indagado informalmente no local o acusado, além de admitir a traficância, declinou que teria recebido as drogas da corré Fabiana, apontando-a aos policiais.

Fabiana estava próxima defronte a um mercadinho situado nas imediações e foi igualmente abordada pelos policiais.

Aqui é importante abrir um parêntese para discussão da tese suscitada pela ré de que teria sido espancada e vítima de abuso de autoridade por partes dos policiais em plena via pública.

O laudo de exame de corpo de delito realizado logo após a prisão da ré não constatou qualquer lesão aparente e ela não fez menção ao médico legista que teria

sido agredida pelos milicianos. À Autoridade Policial Fabiana permaneceu calada ao invés de denunciar os seus supostos algozes.

E vamos mais além: a testemunha presencial Kevin estava no local desde o início durante a abordagem de Fabiana e não mencionou em nenhum momento durante o seu depoimento prestado durante a fase policial que ela teria sido vítima de abuso por parte dos policiais.

Nenhum vídeo ou testemunha foi apresentado por Fabiana.

Para espancar, ainda, a versão da ré, temos o interrogatório do réu Henrique durante a fase investigatória, no qual ele em nenhum momento menciona que Fabiana foi agredida em plena via pública pelos policiais, tendo ele apenas colacionado aos autos essa alegação em juízo durante o seu interrogatório, certamente após ajustar e combinar versões com Fabiana, sem, contudo, convencer este julgador.

Rejeitada, por falta de provas, a tese de Fabiana de abuso de autoridade por parte dos policiais fecho o parêntese quanto a este ponto e retomo do momento em que ela foi abordada pelos policiais.

Fabiana estava na posse das chaves do veículo GM/Celta que se encontrava estacionado nas imediações. Ela estava acompanhada de outra mulher e da testemunha Kevin, no momento em que foi abordada.

De posse das chaves do veículo os policiais realizaram vistoria no veículo que estava sob a responsabilidade da ré Fabiana e localizaram dentro do mesmo 226 porções de cocaína em forma de "crack" e 338 "buchas" de maconha idênticas àquelas apreendidas inicialmente com o acusado Henrique.

Oportuno frisar que além da própria indicação do acusado Henrique de que teria recebido as drogas de Fabiana, as chaves do veículo em questão estavam com ela e foram utilizadas pelos milicianos para a vistoria

Para não ser presa em flagrante Fabiana disse aos policiais que eles poderiam ficar com as drogas encontradas em seu veículo e outras que estavam em sua casa. Do ponto de abordagem os policiais simularam aceitar a oferta e rumaram à residência da acusada (imóvel situado na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 379, bloco V, apto 32, Condomínio Residencial Parque das Flores, Jacareí/SP) e lá após indicação da própria acusada apreenderam uma mala de viagem contendo em seu interior grande quantidade de substâncias entorpecentes e embalagens para acondicionamento de drogas: a) 02 sacos com inúmeros flaconetes pretos vazios; b) 64 flaconetes (pretos e transparentes) contendo cocaína; c) 28 porções de cocaína em forma de "crack"(vários tamanhos) de substância que indicava ser crack; d) 01 balança de precisão; e) 01 pote plásticos verde com várias lâminas de Gillete quebradas e um estilete; f) 06 porções de cocaína; g) 09 tabletes (tipo tijolo), 11 porções e 17 invólucros transparentes de maconha prensada; h) 541 pequenas unidades plásticas de cocaína. A apreensão de drogas na residência da ré somou mais de 10kg de drogas variadas.

Por outro lado, nos termos acima expostos, a acusada admitiu a posse e propriedade das drogas encontradas em sua casa, apresentando a versão esdrúxula de que estaria apenas guardando para um traficante em troca do pagamento de uma dívida. Ainda que esta versão por si só caracterize o tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, ela não condiz com a realidade dos fatos, pois a ré era a responsável pelo abastecimento dos pontos de droga na região, tendo fornecido as substâncias para o corréu Henrique e, ainda, transportava no veículo utilizado por ela naquela data, bem como mantinha em depósito em sua residência grande quantidade de drogas destinada a distribuição.

Pela quantidade de drogas apreendida em poder da ré é possível afirmar que ela era peça importante na distribuição de drogas nesta cidade de Jacareí e naquela região, bem como integrava uma organização criminosa com grande movimentação de dinheiro e substâncias entorpecentes. Afinal, ninguém confiaria a guarda de mais de 10kg de drogas variadas a uma pessoa em troca do pagamento de uma dívida. A versão da ré é fantasiosa e absolutamente inverossímil.

No mais, os policiais militares são funcionários públicos e seus depoimentos não podem ser taxados, a princípio como suspeitos sem comprovação de qualquer intenção dos mesmos em prejudicar os réus, anotando novamente que as alegações de abuso de autoridade e violência não vieram comprovadas no bojo dos autos durante a regular instrução do feito pelas provas documentais e testemunhais obtidas.

Nesse sentido: “Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quanto estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes” (TACRIM-SP, Rel. Gonzaga Franceschini – RJD 18/80).

“Sem o menor cabimento desmerecer a prova testemunhal, com o argumento genérico de que se cuidou de depoimento de policiais. O policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime, em suas várias modalidades. Desmerecer seus testemunhos apenas pela natureza da função que exerce, a par de não ter suporte em qualquer preceito legal, implicaria num imposto preconceituoso e desarrazoado atestado de inidoneidade de toda uma corporação” (TJSP – AP – 1ª C. – Rel. Marcial Holanda – j. 10.04.95 – RT 721/414). (in Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco, Rui Stoco e outros, editora RT, 1999, volume 2, págs. 1833/1835).

Os acusados deverão, portanto, responder pelo crime de tráfico de drogas.

A ré Fabiana, por sua vez, também deverá responder pelo crime de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal), pois ofereceu vantagem ilícita aos policiais para não ser conduzida presa em flagrante.

Por fim, rejeito a acusação referente ao delito do artigo 35, da Lei 11343/06, imputado aos réus.

Melhor analisando a matéria em debate e o escopo do legislador, mormente após a revogação da Lei 6368/76 entendo que para a configuração do delito de associação para a prática dos crimes previstos no artigo 33 e 34 da Lei de Tóxicos exige a efetiva comprovação do animus associativo, bem como da estabilidade e permanência, envolvendo todos os seus membros.

No caso concreto, a despeito dos indícios colhidos durante a fase investigatória e em juízo a respeito de uma associação desenvolvida entre os três réus, não há prova da estabilidade e permanência desta suposta associação.

O fato de a lei estabelecer que a associação, para a configuração do delito do artigo 35, da lei de Drogas, pode envolver a prática reiterada ou não dos delitos previstos nos artigos 33 e 34, do mesmo Diploma Legal, não retira a necessidade de comprovação da estabilidade, permanência e do animus associativo.

Nesse sentido foi o entendimento do Ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça: “Penal e Processual Penal. Recurso Especial. Art. 35, “caput”, da lei nº 11.343/2006. Configuração. Animus Associativo estável e duradouro para a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 34 da lei nº 11.343/2006. Crime autônomo e que

prescinde da prática efetiva dos delitos que motivaram a associação ... I - O tipo previsto no artigo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II - De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos art. 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006..." (REsp nº 1113728/SC, 5ª Turma, j. 29.09.2009).

Na mesma linha é a lição de Vicente Greco Filho: "Haverá necessidade de um 'animus' associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria" (Lei de Drogas Anotada: Lei nº 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2006. pág.120).

No mesmo sentido foi o entendimento recente do Tribunal de Justiça de São Paulo "Apelação Criminal. Tráfico de drogas em associação e posse de munição de arma de fogo de uso restrito. Agentes surpreendidos em plena atividade delituosa no momento em que preparavam quase meio quilo de cocaína Negativas inverossímeis, isoladas e contraditórias Depoimentos dos policiais seguros e convergentes. Prova robusta. Condenação mantida por tráfico mantida. Associação à traficância 'Animus' associativo de caráter permanente e estável. Não demonstração. Absolvição quanto a este delito Crime do Estatuto do Desarmamento Materialidade. Dúvidas sobre a potencialidade lesiva do artefato enquanto munição de arma de fogo. Prova técnica que não exclui a possibilidade de se tratar de cartucho defeituoso, que picotou sem detonar a espoleta Absolvição decretada. Pena do tráfico bem dosada Reparo apenas no índice de aumento pela reincidência de um dos acusados. Regime prisional adequado. Parcial provimento para, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, absolver os réus do crime de associação ao tráfico e, um deles, do delito de posse de munição de arma de fogo de uso restrito, reduzida a pena de outro e mantida, no mais, a r. sentença" (TJ/SP, Apelação criminal nº 990091667684, 1ª Câmara, Relator Des. Péricles Piza, j. 14.12.2009).

Ora, em matéria criminal, onde se busca a verdade real, não há como lastrear um decreto condenatório em provas frágeis e insuficientes.

"É impossível fundar solução condenatória em prova que não conduz a certeza, não bastando a probabilidade, sobre o juízo da existência de certo fato ou mesmo a convicção íntima, sem o concurso de dados objetivos de justificação" (Tacrím - SP - Ap. Rel. Passos de Freitas - RJD 20/176).

Em Direito Penal a prova cabe a quem acusa e não pode ser dirigida a quem se diz inocente. Brilhante, na espécie, a lição de Nicola Framarino Dei Malatesta: "O ordinário do homem é a inocência, por isso ela se presume e é ao acusador que cabe a obrigação da prova no juízo penal. ...Mas quando em geral se trata do ônus da prova em juízo penal, fala-se em obrigação de produzi-la como sustentação de uma dada afirmação. Ora, aberto o juízo penal, aí deverá sempre existir a imputação de crime e, por isso, um acusador e um acusado, bem como uma afirmação acusadora e uma eventual afirmação defensiva. A estas duas asserções se refere o problema do ônus da prova, visando estabelecer qual das duas deve provar-se primeiro. Neste caso, não se poderá nunca dizer que a obrigação da prova incumbe ao juiz que deve pronunciar; o juiz, como tal, não afirma nada, deve julgar entre as várias afirmações e provas; é obrigação sua, como juiz, no momento da produção das provas, limitar-se a colher todas as provas que possam conduzir à verdade judicial, fim supremo de todo processo. Não é, portanto, errôneo, o falar de prova relativamente

ao acusado e acusador. Voltando ao que dizíamos e concluindo, a inocência se presume. Por isso, no juízo penal, a obrigação da prova cabe à acusação" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, tradução Paolo Capitanio, ed. Bookseller, 1996, págs. 134 e 136).

Nessas condições, não havendo nenhuma provas de que os réus se associaram para a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.346/03 torna-se necessária a absolvição dos mesmos quanto ao delito do artigo 35, do mesmo Diploma legal, imputado na denúncia.

3. Passo à dosimetria das penas, adotando-se o critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal.

3.1 ré Fabiana Elizabeth Macanoni:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, aumentada de 1/3, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas durante a diligência em poder da increpada (mais de 10kg de maconha crack e cocaína), ou seja, 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Para o crime do artigo 333, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase reconheço a atenuante da confissão espontânea para o crime de tráfico de drogas e reduzo a reprimenda acima cominada em 1/6, totalizando 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 555 dias-multa.

Não há atenuantes para o crime do artigo 333, do Código Penal e agravantes para ambos os crimes.

Na terceira fase não há causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem consideradas.

Indefiro, nesta oportunidade, a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33, da lei 11.343./06, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendida em poder da acusada (mais de 11kg de maconha, cocaína e crack) e os demais indícios colhidos indicando que a ré era peça fundamental na distribuição de drogas na região, com dedicação efetiva às atividades criminosas, especificamente tráfico de drogas como sua fonte de custeio.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tendo em vista a pena total cominada.

As penas cominadas para ambos os crimes serão somadas, na esteira do artigo 69, do Código Penal.

A ré cumprirá as penas cominadas em regime inicial fechado, único compatível com os crimes cometidos, um deles equiparado a hediondo, e com a gravidade da conduta relatada na inicial acusatória.

3.2 - ré Henrique Oswaldo Carneiro Neto:

Sopesadas as circunstâncias legais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.143/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor fixado no

mínimo.

Na segunda fase de aplicação da pena, pela reincidência específica do réu (fls. 214/216) aumento a pena base fixada em 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena indefiro o pedido de aplicação da causa de redução de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006, por se tratar de réu reincidente específico, não preenchendo, pois, o requisito objetivo.

O réu cumprirá a pena em regime inicial fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei 8072/90, anotando-se que o mesmo é reincidente específico, justificando ainda mais a fixação do regime mais gravoso.

Finalizando, tendo em vista, de um lado, a primariedade da ré Fabiana e a ampla possibilidade de discussão de teses em segundo grau de jurisdição para possível obtenção de benefícios previstos na legislação penal e processual penal em vigor, e de outro, a substancial linha argumentativa colacionada pela Defesa do réu Henrique, com questionamentos em relação às provas produzidas durante a fase policial e em juízo, preservando sempre o duplo grau de jurisdição, o princípio da não culpabilidade, entendo que os réus poderão recorrer desta sentença em liberdade, não havendo motivo para manutenção de suas prisões cautelares.

Revogo, portanto, as prisões preventivas de ambos os acusados, concedendo-lhes o benefício da liberdade provisória mediante cumprimento de todos os requisitos de praxe, fixando-se, ainda, a medida cautelar prevista no artigo 319, I, do CPP (comparecimento mensal em juízo para comprovar e justificar as suas atividades).

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para o fim de:

A) CONDENAR a ré FABIANA ELIZABETH MACANONI a cumprir a penas de> a1) 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 555 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06; b) 02 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 333 do Código Penal, ABSOLVENDO-A do crime do artigo 35, da Lei 11343/06, que lhe foi imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

B) CONDENAR o réu HENRIQUE OSWALDO CARNEIRO NETO a cumprir a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06, ABSOLVENDO-O do crime do artigo 35, da Lei 11343/06, que lhe foi imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Revogadas as prisões preventivas dos acusados nesta oportunidade determino a expedição de alvarás de soltura clausulados.

Determino o confisco dos bens apreendidos, de origem ilícita, nos termos do artigo 243, § único, da Constituição Federal de 1988.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos réus, iniciando-se a fase executória definitiva.

Jacarei, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA